

罪数に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、転売目的でA所有のバッグを盗み、自宅に持ち帰ったが、転売先が見付からなかったため、同バッグを焼却した。この場合、甲に窃盗罪及び器物損壊罪が成立し、両罪は併合罪となる。
2. 甲は、乙に対し、「バッグを盗んできたら売却してやる。」などと言って窃盗を教唆し、乙が盗んだバッグを受け取り、同バッグの売却をあっせんした。この場合、甲に窃盗教唆罪及び盗品等有償処分あっせん罪が成立し、両罪は併合罪となる。
3. 甲は、当初より代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って、民宿において朝食付きの宿泊利用を申し込み、同民宿に宿泊し、かつ、同民宿で朝食の提供を受けた。この場合、甲に刑法第246条第1項の詐欺罪及び同条第2項の詐欺罪が成立し、両罪は併合罪となる。
4. 甲は、真実は募金を災害復興支援のために使うつもりはなく、自己のために費消するつもりであるのにこれを隠して、事情を知らない多数のアルバイトの募金活動員に、連日、駅前で募金箱を持たせ、「災害復興支援のために募金をお願いします。」と連呼させ、多数回にわたり、不特定多数の通行人からそれぞれ少額の現金を募金箱に投入させてだまし取った。この場合、甲に詐欺罪の包括一罪が成立する。
5. 甲は、他人から盗んだクレジットカードを使用して商品をだまし取ろうと考え、A名義のクレジットカードを窃取し、家電量販店において、店員に対し、Aに成り済まして同クレジットカードを提示して商品の購入を申し込んだが、同店員に盗難カードであることを見破られたため、商品を手に入れることができなかった。この場合、甲に窃盗罪及び詐欺未遂罪が成立し、両罪は牽連犯となる。

No202	罪 数	正答率
共通R6-7	正 解 2、4 (順不同)	87%

1 誤っている

本記述のように窃盗犯人が窃取した財物を損壊した場合、器物損壊罪に当たる行為は、不可罰的(共罰的)事後行為として窃盗罪に吸収され、窃盗罪のみが成立する。

2 正しい

大判明 42.3.16 は、窃盗教唆罪と贓物故買罪〔現行法の盗品等有償譲受罪に相当する。〕とは法律上その罪質を異にするから、教唆して窃取させた贓物を譲り受けたとしても、その譲受行為は、窃盗教唆罪の中に吸収されるべきものというができないとしている。したがって、窃盗を教唆して盗ませたバッグの売却をあっせんした場合、窃盗教唆罪及び盗品等有償処分あっせん罪が成立し、両罪は併合罪となる。

3 誤っている

当初より代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って、民宿において宿泊利用を申し込んで宿泊し、食事の提供を受けた場合、役務の提供に重点があることから、刑法 246 条 2 項の詐欺罪のみが成立する。

4 正しい

最決平 22.3.17 は、本記述と同様の事案において、当該行為は、「不特定多数の通行人一般に対し、一括して、……同一内容の定型的な働き掛けを行って寄付を募るという態様のものであり、かつ、被告人の 1 個の意思、企図に基づき継続して行われた活動であったと認められる。加えて、このような街頭募金においては、これに応じる被害者は、比較的少額の現金を募金箱に投入すると、そのまま名前も告げずに立ち去ってしまうのが通例であり、募金箱に投入された現金は直ちに他の被害者が投入したものと混和して特定性を失うものであって、個々に区別して受領するものではない。以上のような本件街頭募金詐欺の特徴にかんがみると、これを一体のものと評価して包括一罪と解した原判断は是認できる。」としている。

5 誤っている

牽連犯となるには、行為者が主観的にその一方を他方の手段又は結果の関係において実行しただけでは足りず、その「数罪間にその罪責上通例手段結果の関係が存在す」かどうかで決まる(最大判昭 24.12.21)。本記述のように甲が窃取したクレジットカードを使用して商品をだまし取ろうと考えた場合でも、窃盗罪及び詐欺未遂罪の間に通例、手段結果の関係はなく、両罪は併合罪となる。

以上により、正しい記述は 2 と 4 であり、したがって、正解は肢 2 と肢 4 (順不同) となる。